Proc. n. 11577/01 R.G.N.R.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott. Pier Luigi di Bari, all' udienza dibattimentale del 21/07/2005, con l'intervento del P.M. Dott. Giylapian e con l'assistenza del cancelliere Proietti, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della seguente

SENTENZA DIBATTIMENTALE

nei confronti di:

1) C. G., nato a ***** il **/**/****, ivi residente in via *********

- contumace -

2) C. S. nato a ***** il **/**/****, ivi residente in via *********

- contumace -

Svolgimento del processo

Con decreto notificato il 25/03/03, C. S. e C. G. venivano citati in giudizio per rispondere, davanti a questo Tribunale, della violazione degli artt. 615 ter e quinquies, 81 cpv., 110 c.p., come da rubrica.

All'udienza del 13/6/03, dichiarata la contumacia degli imputati, venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti: il Tribunale si riservava di disporre eventualmente la perizia, richiesta dalla difesa in ordine al funzionamento del codice virale, all'esito delle prove espletande.

Alla successiva udienza del 27/11/03, il Tribunale respingeva la richiesta della difesa di assoluzione ex art. 129 c.p.p. per mancanza di querela per la prima fattispecie criminosa, ritenendo che nella descrizione, contenuta nel capo di imputazione, del fatto integrante il reato di cui all'art. 615 ter c.p., vi fosse il riferimento al danneggiamento di programmi ed al loro malfunzionamento: si riteneva, pertanto, che il reato fosse procedibile d'ufficio, stante la contestazione, in fatto, dell'aggravante di cui all'art. 615 ter, secondo comma n. 3 c.p.

Nella medesima udienza venivano assunte le testimonianze del Cap. G.d.F. R. D. sulla attività generale di p.g. svolta per la individuazione dell'autore del programma, del M.llo. G.d.F. D. F. G. sulle operazioni di p.g. svolte presso Tiscali s.p.a., di B.C., responsabile di Tiscali s.p.a. per i rapporti con l'A.G., sull'attività di esecuzione del decreto di esibizione di tracce telematiche della Procura di Milano, del M.llo G.d.F. M. G. sulla attività di p.g. svolta presso l'abitazione dei C..

Nel corso dell'udienza si acquisiva, con il consenso delle parti, il decreto di esibizione ed il verbale di sequestro relativi al provider Tiscali s.p.a., nonché - previa emissione di apposita ordinanza - la comunicazione della predetta società relativa agli accessi effettuati per amministrare lo spazio web contenente il worm.

Veniva altresì prodotta memoria difensiva ex art. 121 c.p.p. per motivare le precedenti istanze istruttorie dirette ad ottenere l'ammissione di una perizia e l'esibizione del corpo di reato (che

INTERNATIONAL TRADERS www.intertraders.eu

veniva depositato all'udienza successiva).

All'udienza del 27 maggio 2004 venivano assunte le testimonianze di Ferrero Roberto, responsabile dell'Ufficio supporto Enti Istituzionali di Wind Telecomunicazioni s.p.a. (ex Infostrada), sull'attività di esecuzione del decreto di esibizione di tracce telematiche della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, e dell'ex M.llo G.d.F. F. D. sul sequestro operato presso il C. e l'analisi del materiale rinvenuto: nel corso di questa testimonianza, con il consenso delle parti, si acquisiva l'allegato n. 1 alla nota di p.g. del 28/3/01 e copia delle regola di condotta e procedura forense I.A.C.I.S.

Alla stessa udienza venivano letti ed acquisiti ex art. 513 c.p.p., stante la loro contumacia e la non opposizione delle parti, i verbali di interrogatorio resi dagli imputati il 07/09/01: veniva, inoltre, depositata memoria difensiva ex art. 121 c.p.p. con i relativi allegati.

All'udienza del 23/9/04, con il consenso delle parti, si acquisivano le note di p.g. della G.d.F. di Milano del 13/03/01, 19/03/01, 28/3/01, 15/5/01 e veniva depositata altra memoria difensiva ex art. 121 c.p.p. a sostegno della richiesta di perizia, che, all'udienza successiva del 20 ottobre, veniva respinta con ordinanza, in quanto ritenuta non necessaria.

Infine, dichiarata terminata l'istruttoria dibattimentale, nelle udienze del 24/2/05 e del 21/7/05, il P.M. ed i difensori concludevano rispettivamente come da verbale.

Motivi della decisione

1. Fatto e fonti di prova

L'imputato C. G. va ritenuto l'esclusivo colpevole dei reati di cui al capo di imputazione, avendo diffuso il programma informatico denominato "Vereika" di sua creazione, avente per effetto l'alterazione del funzionamento di sistemi informatici, ed essendosi introdotto abusivamente in sistemi informatici altrui in modo aggravato ai sensi dell'art. 615 ter, co. 2 n. 2-3, c.p..

Si perviene a tale conclusione processuale in forza delle seguenti fonti di prova: 1) verbali di perquisizione e sequestro operato il 21 marzo 2001 dalla Polizia Tributaria della Lombardia a carico di C. G. e S.; 2) verbale di acquisizione di tracce telematiche del 14 marzo 2001 eseguita presso Infostrada s.p.a. dalla Polizia Tributaria della Lombardia; 3) documento prot. SEI 010313009355 e SEI 010314009405 di Infostrada s.p.a. relativo all'amministrazione dello spazio web digilander.iol.it/vierika/index.html (fax del 16/3/01); 4) verbale di esibizione e sequestro del 14 marzo 2001 eseguito presso Tiscali s.p.a. dalla Polizia Tributaria della Sardegna; 5) comunicazione e-mail Tiscali s.p.a. del 14 marzo 2001 relativa all'amministrazione del sito web.tiscalinet.it/krivojrog/vierika/Vindex.html; 4) annotazioni di p.g. della Polizia Tributaria della Lombardia del 13/3/01, 19/3/01, 28/3/01 (con all. n. 1), 15/5/01; 5) testimonianze di F. D., R. D., B. C., M. G.; 6) verbale di interrogatorio dell'imputato del 7 settembre 2001.

2. Il worm Vierika

L'istruttoria dibattimentale, in particolare le testimonianze di F. D.[1] e R. D.[2], e le annotazioni di

p.g. agli atti[3], hanno permesso di accertare che Vierika[4] è un internet worm programmato in Visual Basic Script, i cui effetti derivano dalla interazione di due script differenti.

Il primo, di piccole dimensioni, è allegato come attachment ad una e-mail: tale lettera contiene infatti il file Vierika.JPG.vbs, mentre il subject è "Vierika is here" e nel testo viene indicato "Vierika.jpg".

Una volta eseguito, il programma agisce sul registro di configurazione di Windows[5], abbassando al livello minimo le impostazioni di protezione del browser Internet Explorer ed inserendo come home page del predetto browser la pagina web http://web.tiscalinet.it/krivojrog/vierika/Vindex.html.

Il secondo script in Visual Basic, di dimensioni maggiori, è contenuto nel documento html Vindex.html[6], e si attiva quando l'utente, collegandosi ad Internet, viene automaticamente indirizzato dal browser sulla nuova home page sopra indicata: il basso livello di protezione impostato dalla prima parte del codice, permette l'automatica esecuzione dello script contenuto nel documento html.

L'effetto di questo secondo script è quello di creare nella prima partizione del primo disco rigido del computer il file c:\Vierika.JPG.vbs, contenente la prima parte del codice, e di produrre un effetto di mass-mailing, inviando agli indirizzi contenuti nella rubrica di Outlook una e-mail contenente l'attachment sopra descritto, in modo tale che il programma Vierika si autoreplichi[7].

3. Individuazione dell'imputato ed accertamento della sua condotta

Alla identificazione dell'imputato la Guardia di Finanza di Milano perveniva attraverso una indagine iniziata il 5 marzo 2001 dopo aver ricevuto una e-mail contenente il primo script del programma, come sopra descritto: la p.g. individuò due siti web, uno sul server di Tiscali s.p.a. (contenente il secondo script), e l'altro sul server di Infostrada s.p.a.[8], aventi nella propria url il nome Vierika[9].

Lo stesso giorno Tiscali s.p.a., su segnalazione informale della G.d.F. di Milano[10], provvedette a sospendere l'accesso al sito web.tiscalinet.it/krivojrog/vierika/Vindex.html [11]: vennero poi emessi dalla Procura di Milano, ed eseguiti, due decreti di esibizione e sequestro delle tracce telematiche relative ai due siti indicati.

Dai dati forniti dal gestore Tiscali s.p.a., la cui documentazione è agli atti, risultavano interventi di gestione del sito web.tiscalinet.it/krivojrog/vierika/Vindex.html relativi all'11/12/00 ed alla notte del 3/3/01[12] ad opera dell'utente con username krivoj, registrato presso il provider con i dati di identificazione e di residenza di C. G.: utente che si connetteva al server mediante una linea telefonica risultata intestata a C. S..

Dai dati forniti dal gestore Infostrada s.p.a. risultava che nella notte del 3 marzo 2001 l'utente avente come username krivoj[13] - registrato anche presso questo provider con gli estremi di identificazione e di residenza di C. G. - realizzava sei interventi di amministrazione sul sito digilander.iol.it/vierika/index.html, connettendosi al server mediante la medesima utenza telefonica sopra indicata.

L'ultimo intervento di gestione risultava effettuato, dal medesimo utente e con la stessa linea telefonica, nella notte del 12 marzo 2001: alle ore 9,01 del 14/03/01 l'utente disattivava il proprio account presso il provider Infostrada s.p.a.

Sulla base dei dati acquisiti, in esecuzione di attività delegata dalla Procura di Milano, il 21 marzo 2001 la G.d.F. di Milano eseguiva una perquisizione presso l'abitazione dei fratelli C., ove C. G., di professione consulente informatico, risultava avere anche la sede della propria attività: in quella circostanza l'imputato, assuntasi la paternità del programma, indicava alla p.g. i files relativi al programma Vierika contenuti nel proprio disco rigido[14], masterizzandone copie da sottoporre a sequestro sotto il controllo degli agenti[15].

In sede di interrogatorio, il 7 settembre 2001, C. G. confermava di avere creato e diffuso il programma Vierika.

4. Il problema del metodo e gli accertamenti tecnici di parte

La difesa dell'imputato sia nel corso dell'istruttoria, che nell'arringa finale ha reiteratamente posto in discussione la correttezza sia del metodo utilizzato dalla p.g. per estrarre i programmi dal computer del C., che di quello applicato dalla p.g. e dalle società Infostrada s.p.a. e Tiscali s.p.a. per individuare l'amministratore degli spazi web (uno dei quali contenente il secondo script del programma Vierika).

Il tema è, in termini generali, di non poco momento e certamente dovrà essere affrontato in maniera approfondita anche dalla giurisprudenza, ma appare nella fattispecie in esame di seconD. rilievo.

Occorre innanzitutto precisare che non è compito di questo Tribunale determinare un protocollo relativo alle procedure informatiche forensi, ma semmai verificare se il metodo utilizzato dalla p.g. nel caso in esame abbia concretamente alterato alcuni dei dati ricercati.

In altre parole, non è permesso al Tribunale escludere a priori i risultati di una tecnica informatica utilizzata a fini forensi solo perché alcune fonti ritengono ve ne siano di più scientificamente corrette, in assenza della allegazione di fatti che suggeriscano che si possa essere astrattamente verificata nel caso concreto una qualsiasi forma di alterazione dei dati e senza che venga indicata la fase delle procedure durante la quale si ritiene essere avvenuta la possibile alterazione.

In termini generali, quando anche il metodo utilizzato dalla p.g. non dovesse ritenersi conforme alla migliore pratica scientifica, in difetto di prova di una alterazione concreta, conduce a risultati che sono, per il principio di cui all'art. 192 c.p.p., liberamente valutabili dal giudice alla luce del contesto probatorio complessivo (fermo restando che maggiore è la scientificità del metodo scelto, minori saranno i riscontri che il giudice è chiamato a considerare per ritenere attendibili gli esiti delle operazioni tecniche).

Facendo applicazione di tali principi nel caso in esame, deve evidenziarsi come la difesa si sia limitata ad allegare che i metodi utilizzati, non essendo conformi a quelli previsti dalla (supposta) migliore pratica scientifica, conducono a risultati che non possono essere ritenuti ab origine attendibili, senza peraltro allegare che nel caso concreto si è prodotta una qualche forma di alterazione o che avrebbe potuto prodursene alcuna, indicandone la possibile fonte, forma e fase di azione.

Gli accertamenti compiuti dalla p.g. in ordine alle tracce telematiche possono ritenersi pienamente attendibili alla luce del contesto probatorio complessivo (confermando, indirettamente, che il metodo utilizzato non ne ha alterato gli esiti).

Da una parte, infatti, i dati consegnati alla p.g. dal provider Tiscali (gli interventi di amministrazione sul sito http://web.tiscalinet.it/krivojrog/vierika/Vindex.html avvenivano da parte

INTERNATIONAL TRADERS
www.intertraders.eu

dell'utente con username krivoj, registrata presso il provider con i dati identificativi del C.; le connessioni avvenivano per mezzo della utenza telefonica intestata al fratello, S., di C. G.) trovano un riscontro incrociato con quelli forniti dal provider Infostrada[16] (gli interventi di amministrazione sul sito digilander.iol.it/vierika/index.html avvenivano da parte dell'utente con username krivoj, registrata presso il provider con i dati identificativi del C.; le connessioni avvenivano per mezzo della utenza telefonica intestata al fratello del C.; l'imputato, in sede di interrogatorio, ha confermato di operare ancora sul sito digilander.iol.it/vierika), dall'altra, l'assunzione della paternità del programma fatta dal C. in sede di interrogatorio, rende puro esercizio accademico l'affrontare più approfonditamente la questione del metodo.

Il C., infatti, in sede di interrogatorio dichiara espressamente di aver creato e diffuso il programma denominato Vierika, e già in precedenza, al momento della perquisizione domiciliare, lo aveva indicato alla p.g. operante, masterizzandone le copie da sottoporre a sequestro sotto il controllo degli agenti.

Quanto al funzionamento del programma, non sembra che la complessiva impostazione difensiva abbia posto seriamente in discussione il meccanismo sopra descritto, avendo appuntato le proprie critiche, anche con l'ausilio di tecnici, su aspetti del funzionamento e degli effetti del programma, ipotizzati o ritenuti dalla p.g., che in questa sede non sono stati ritenuti rilevanti ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Le attenzioni della difesa, nella memoria depositata alla udienza del 23/6/04, si sono concentrate sul fatto che il programma interagisce solo con Outlook e non con la più diffusa versione Outlook Express; su correzioni terminologiche (come il riferimento improprio ai programmi "sorgente" sequestrati all'imputato) o sulle valutazioni del teste F., in particolare in ordine alla potenziale diffusività del programma; sulle generalizzazioni ed esemplificazioni contenute nelle note di p.g.

Dalle stesse considerazioni della difesa si ricava, peraltro, che "Vierika è un codice autoreplicante in due parti...in grado di infettare...le macchine con Windows 95 o 98 con istallato il software "Outlook Professional" della piattaforma "Microsoft Office", p. 2; si legge ancora che "se andiamo a leggere il codice di Vierika, troviamo che esso chiama funzioni dell'interfaccia MAPI completa, in particolare per acquisire gli indirizzi dalla rubrica", p. 3; a p. 5 si contesta la sussumibilità delle impostazioni di protezione di Internet Explorer nel concetto normativo di misure di sicurezza, ma non che il programma apponesse tali modifiche, tanto più che - si spiega - per ripristinare le impostazioni originarie sarebbero bastati "quattro click del mouse"; si contesta la ingannevolezza del messaggio e-mail portatore del programma, ma non il fatto che abbia una doppia estensione e contenga un codice eseguibile; si contesta che il programma abbia un funzionamento di tipo "troiano" con appropriazione e diffusione di dati riservati, ma si ammette che esplica "funzioni di mailing del software Outlook installato sulla macchina al fine di autoreplicarsi", p. 9; a p. 22 si riconosce che Vierika è un worm che si autodiffonde utilizzando gli indirizzi di posta elettronica e che si manifesta come allegato di posta elettronica.

Conferma del fatto che le operazioni di copiatura del programma Vierika, avvenute nel corso della perquisizione domiciliare, non ne hanno in concreto prodotto alcuna alterazione, deriva dal fatto che i risultati dell'analisi della copia sequestrata sono del tutto conformi alla descrizione del suo funzionamento operata dalla p.g.[17] e da una società produttrice di antivirus[18] in un momento antecedente al sequestro operato presso l'abitazione del C.: descrizione, come sopra riportata al punto 2, che non poteva, pertanto, risentire di ipotetiche ed astratte alterazioni dovute alle successive operazioni tecniche poste in essere dalla p.g.

Non può, inoltre, non evidenziarsi che la difesa si è limitata a porre suggestivamente la questione in ordine alla metodologia di sequestro del programma: non ha, invece, allegato la sua avvenuta

alterazione in concreto, nonostante la disponibilità della versione da cui fu copiato il programma successivamente analizzato dalla p.g., rimasta nel possesso dell'imputato, le avrebbe permesso l'accertamento e l'allegazione di eventuali anomalie.

Non solo il disco rigido dell'indagato non fu sottoposto a sequestro, ma non risulta che vennero nemmeno rimossi i files trovati nel computer del C.: venne, infatti, sottoposta a sequestro una loro copia masterizzata su cd, lasciando gli originali nella disponibilità dell'imputato (teste F. p. 22).

Appare in questa sede opportuno precisare che non si è ritenuto necessario disporre una perizia volta ad esplicare il funzionamento del programma: da una parte, infatti, i testi di p.g. (in particolare, F. D.) avevano le competenze tecniche necessarie per la decifrazione del codice, dall'altra si è ritenuto che la difesa non abbia in sostanza contestato i meccanismi di funzionamento del programma, come esplicitati dai testi escussi e sopra descritti al punto 2, nonostante si sia servita anche della collaborazione di un esperto informatico (per criticare e contestare, come si è detto, aspetti della deposizione del teste F. che non sono stati valorizzati in questa sede).

Deve inoltre sottolinearsi che gli elementi di conoscenza probatoria di cui dispone il Tribunale poggiano anche su produzioni documentali assunte con il consenso delle parti, come la cd. analisi tecnica redatta da F. D. ed allegata alla nota di p.g. del 15/5/01 e la documentazione relativa ai files sequestrati nel computer dell'imputato (all. 1 alla nota di p.g. del 28/3/01).

Si ritiene, pertanto, che il contraddittorio si sia svolto anche su di essi, mettendo il giudice in condizioni di poter ricostruire adeguatamente gli aspetti rilevanti della condotta materiale del C. e di compiere le opportune valutazioni di tipo giuridico, comprese quelle inerenti l'elemento soggettivo del reato.

Non ignora il Tribunale l'emergere di un orientamento della Suprema Corte, non consolidato, che sembrerebbe adombrare una qualche forma di cogenza della perizia, ogni qual volta la ricognizione del reato presupponga accertamenti di tipo tecnico (Cass. pen., sez. III, n. 4686/05, Corsi; Cass. pen., sez. V, n. 5672/05, Scoppa).

Deve peraltro constatarsi che tale orientamento pretermette, senza alcun accenno motivazionale, il tradizionale insegnamento secondo il quale la perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito, anche in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalle parti, la valutazione della necessità di disporre indagini specifiche (cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 34089/03, Bombino).

Nella fattispecie in esame la difesa, nonostante abbia presentato quattro memorie ex art. 121 c.p.p., non ha prodotto alcun documento o parere che disconosca il funzionamento del worm nei suoi aspetti delineati al punto 2, gli unici valorizzati in questa sede: a fronte della descrizione del codice operata dalla p.g., non ha invero allegato un diverso funzionamento del programma, chiedendone l'accertamento ad opera di un perito.

Sotto altro aspetto, il menzionato orientamento giurisprudenziale non consente un agevole coordinamento tra il principio del libero convincimento del giudice e quello del contraddittorio tra le parti.

Tradizionalmente, infatti, in forza del primo principio, il giudice può valorizzare un accertamento di parte che sia ritenuto esaustivo, corretto ed appropriato, senza necessità di accertamenti ulteriori.

In tal caso, la tutela delle parti, siano esse pubbliche o private, si esplica in primo luogo a livello motivazionale, dovendo l'organo giudicante dare compiuta contezza dei risultati raggiunti: qualora

ritenga di aderire alla prospettazione tecnica di una delle parti, non è peraltro gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle conclusioni raggiunte e dell'erroneità di tutte quelle espresse, dovendosi considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni e le argomentazioni delle parti (cfr. su tale tematica Cass. pen., sez. IV, n. 34379/04, Spapperi).

Del resto non avrebbe senso imporre una sorta di accertamento vincolato mediante perizia, lasciando poi libero l'organo giudicante, peritus peritorum, di disconoscerne motivatamente i risultati, come da sempre viene riconosciuto in giurisprudenza.

Tali conclusioni potrebbero trovare conferma indiretta anche dalla analisi della fattispecie concreta sottoposta al giudizio di una delle pronunce innovative sopra richiamate (Cass. pen. n. 5672/05, cit.): il risultato a cui essa perviene si fonda, infatti, sulla censura di difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine al rigetto di una istanza di perizia dibattimentale e sul fatto che un teste riferisse de relato le conclusioni a cui era giunto personale di p.g., esprimendo considerazioni tecniche riferite ad un'attività da lui non direttamente espletata (a differenza del caso in esame, in cui i testi sono stati escussi sulla attività da loro condotta).

Quanto al principio del contraddittorio, la parità di armi fra accusa e difesa si garantisce non solo con il controesame del teste esperto addotto da una delle parti, ma con la facoltà di dedurre testimoni e produrre documenti e memorie, anche avvalendosi di consulenti tecnici (per la considerazione che il diritto alla controprova non può, invece, avere ad oggetto l'espletamento di una perizia, essendo questo mezzo di prova di per sé neutro, cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 275/96, Tornabene).

Ed è proprio uno dei pochi passaggi argomentativi di Cass. pen., n. 4686/05, cit., che conferma come la perizia non possa ritenersi cogente, laddove, richiamando l'art. 360 c.p.p., ricorda che, in caso di accertamenti tecnici irripetibili, il PM deve consentire alla parte di parteciparvi con un proprio consulente.

Il fatto che anche nel caso degli accertamenti non più ripetibili eseguiti da una delle parti non sia prevista l'obbligatorietà della perizia, nonostante nessuna operazione tecnica ulteriore potrà più essere disposta in dibattimento, dimostra che il legislatore ha essenzialmente concepito il contraddittorio come sufficientemente garantito dalla possibilità per le parti di partecipare, in proprio o mediante consulenti, agli accertamenti tecnici.

La facoltà che esse hanno di promuovere incidente probatorio non mina tale ragionamento, ma trova spiegazione nel fatto che, mentre nel caso di accertamenti ripetibili le risultanze di parte saranno sottoposte alla valutazione imparziale del giudice, il quale potrà disporre un nuovo accertamento peritale qualora le ritenga insufficienti od inidonee, nel caso degli atti urgenti, l'impossibilità di ripetizione dell'atto ed il principio del contraddittorio suggeriscono l'immediato riconoscimento alle parti della facoltà di sollecitare ed anticipare la funzione di terzietà e controllo che è propria dell'organo giudicante.

5. Il reato di cui all'art. 615 quinquies c.p.

Deve ritenersi che C. G. abbia commesso il reato di cui all'art. 615 quinquies c.p., avendo diffuso il programma denominato Vierika, da lui creato, avente per scopo ed effetto l'alterazione di alcune delle funzionalità telematiche di sistemi informatici.

La diffusione del programma, oltre che dalle circostanze che nel prosieguo verranno indicate e dalle

INTERNATIONAL TRADERS
www.intertraders.eu

quali si desumono gli accessi abusivi commessi[19], si evince dalle dichiarazioni dell'indagato che, in sede di interrogatorio, ammette di averlo diffuso, inviandolo ad alcuni indirizzi di posta elettronica reperiti sulla bacheca elettronica del sito www.sexualcyber.com/annunc.htm.

Non vi è dubbio, a parere del Tribunale, che il programma creato dall'imputato abbia come scopo ed effetto quello di alterare una parte del funzionamento dei sistemi informatici aggrediti.

Infatti, gli effetti complessivi creati dai due script di cui è composta Vierika, integrano una modificazione dell'ordinario modo di funzionare dei programmi Internet Explorer ed Outlook, dal momento che l'invio automatico di e-mail e l'autonoma modifica dei parametri di protezione del browser, senza alcuna conoscenza da parte dell'utente ed in assenza della digitazione degli appositi comandi da parte sua, costituiscono comportamento anormale del sistema.

L'impostazione accolta sembra trovare riscontro nella fattispecie sottoposta all'esame di Cass. pen., sez. II, n. 17295/04, Nicolai, ove viene avallata l'interpretazione dei giudici di merito, secondo i quali la modifica dei parametri di connessione ad internet occultamente realizzata da un software dialer integra il concetto di alterazione rilevante agli effetti di cui all'art. 640 ter c.p.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, si ritiene sufficiente l'accertata volontà dell'imputato di diffondere il programma con la consapevolezza dei suoi effetti (conoscenza derivante dall'esserne il C. l'autore), non esigendo la norma che il fine dell'agente sia diretto alla distruzione od al danneggiamento del sistema.

Non sembra che il dolo possa venire escluso dalle motivazioni che hanno spinto il C. a realizzare Vierika, da lui ricondotte, in occasione dell'interrogatorio, a fini di studio e ricerca, e dal suo difensore a fini ludici: infatti, esse non elidono, ma anzi presuppongono, la volontà di diffusione del programma con la conoscenza dei suoi effetti ed integrano, semplicemente, il movente del reato (apprezzabile in sede di trattamento sanzionatorio).

Né, per il principio ignorantia legis non excusat, ha alcun rilievo scriminante la convinzione dell'imputato, quale si ricava dall'interrogatorio, che gli effetti del programma dai lui creato non integrerebbero gli elementi oggettivi delle due fattispecie criminose contestategli.

Peraltro, un'analisi cronologica degli accadimenti, alla luce dell'esame di tutti i programmi rinvenuti nel computer dell'imputato[20], consente di dare maggiore intensità alla volontà dell'imputato di realizzare il fatto delittuoso.

Il C., infatti, nella notte del 3 marzo 2001, dopo aver effettuato un lungo accesso sul sito ospitato da Tiscali s.p.a., si collega con l'altro sito web presente sul server di Infostrada s.p.a.: al termine di queste connessioni, dopo le nove del mattino, apporta le ultime modifiche ai files Vierika.jpg.vbs e Valecalda.vbs, entrambi rinvenuti nel suo pc e contenti il codice Vierika.

Il 5 marzo, su segnalazione di clienti e della G.d.F. (che, oltre a ricevere in proprio il programma con una e-mail, ha constatato che su internet ne è già stata segnalata la presenza), Tiscali s.p.a. impedisce agli utenti l'accesso al sito contenente la seconda parte dello script, in modo da bloccare la diffusione del programma.

Il 7 marzo, dopo aver probabilmente rilevato che il sito sul server di Tiscali s.p.a. era stato oscurato, C. modifica cinque programmi aventi il medesimo codice di Vierika, ma nei quali il comando relativo alla modifica della home page del browser fa riferimento al sito ospitato sul server di Infostrada s.p.a. (Edit1.txt, Edit2.txt, Edit4.txt, Finale.txt, Copia di edit2.vbs).

INTERNATIONAL TRADERS
www.intertraders.eu

Nella notte del 14 marzo, qualche ora prima che vengano notificati i decreti di esibizione e sequestro ai due provider, l'imputato apporta le ultime modifiche ad alcuni programmi rinvenuti nel suo computer.

Fra questi i files Newvirus.txt, NewVirus2.txt, Vierika.jpg.txt (contenenti le istruzioni per impostare come home page la pagina digilander.iol.it/vierika e far comparire come soggetto delle e-mail la significativa scritta "Vierika è tornata"), ed il file Newvirus2.vbs, contenente le istruzioni per far inviare dai computer infetti una e-mail anche all'indirizzo abuse@libero.it (attraverso il quale Infostrada s.p.a. gestisce le segnalazioni relative alla sicurezza informatica): e-mail avente nel soggetto "ragazzi non scherzate..." e nel testo "certe cose non si dovrebbero mai fare...", nonché un attachment (autoexec.bat).

Nella notte del 14 marzo le ultime operazioni C. le svolge su tre programmi (Laura.jpg.txt, Viruslibero.txt, Copia di Viruslibero.vbs) aventi l'effetto di far inviare dai computer infettati 300 e-mail all'indirizzo di posta elettronica abuse@libero.it (nota di p.g. G.d.F. Milano del 28/3/01, p. 3.).

Alle nove del mattino del 14 marzo C. disattiva il proprio account presso Infostrada s.p.a. (l'ultimo accesso al sito digilander.iol.it/vierika/index.html era avvenuto nella notte del 12 marzo).

La sequenza temporale descritta, oltre a dimostrare la piena consapevolezza dell'imputato in ordine agli effetti prodotti dal proprio programma, induce a ritenere che il C. stesse progettando interventi sempre più complessi e pregiudizievoli.

6. Il reato di cui all'art. 615 ter c.p.

Esistono indizi gravi, precisi e concordanti dell'avvenuta introduzione del C., per mezzo del programma da lui creato, all'interno di sistemi informatici altrui protetti da misure di sicurezza.

Tale introduzione si ricava dalle segnalazioni sulla diffusione del virus che vennero fatte da alcune società di sicurezza informatica[21], dalle lamentele che alcuni clienti presentarono a Tiscali s.p.a. poiché ospitava il programma sui propri spazi web[22], e dai dati numerici presenti nel counter del sito web.tiscalinet.it/krivojrog/vierika/Vindex.html, dal quale risultavano 829 visite (cfr. teste Cap. R. p. 27; nota di p.g. G.d.F. Milano del 13/3/01, p. 3).

Non vi è dubbio che l'introduzione - la quale sussiste ogni volta che vengano sorpassati gli ostacoli che presidiano l'accesso al sistema e che non presuppone necessariamente che il reo sia in grado di poter richiamare e disporre dei dati e programmi contenuti nel computer violato - sia avvenuta abusivamente, dovendosi a tal fine apprezzare la natura, le finalità e le modalità della condotta del C., volte ad aggirare il jus prohibendi dei titolari.

Vengono in rilievo soprattutto le modalità dell'azione, dirette a manipolare con l'inganno (primo script del programma) e clandestinamente (secondo script) la volontà dell'utente.

L'abusività discende, innanzitutto, dalla fraudolenta induzione in errore dell'utente che riceveva l'e-mail sull'esistenza di un'immagine: infatti, il file Vierika, presentava una doppia estensione che, all'epoca, secondo le impostazioni di default di Outlook, non veniva visualizzata dall'utente per intero (salvo questi avesse cambiato le impostazioni predefinite)[23], poiché il sistema mostrava solo la prima, relativa al formato jpg.

L'estensione jpg indicava la presenza di un'immagine allegata al messaggio e quest'ultimo ne suggeriva l'inerenza ad una figura femminile (nel soggetto compariva, infatti, la scritta "Vierika is

here”), sicché l’utente era portato ad acconsentire alla esecuzione del file associato (richiesta di esecuzione che non pare venisse, peraltro, formulata in modo esplicito, ma mascherata dietro l’innocua richiesta all’utente di esprimere il suo consenso a vedere la foto)[24]: immagine non presente nell’allegato, che conteneva solo uno script in Visual Basic[25].

Indipendentemente, pertanto, dalla visualizzazione completa del file, la maliziosa scelta del C. di impostare quale prima estensione dell’attachment quella relativa ad un oggetto che stimolava la curiosità dell’utente e che non sussisteva, doveva ritenersi volta ad aggirare fraudolentemente la volontà del destinatario.

Sintomi di tale fraudolenza si ricavano, inoltre, dal fatto che il C. non si presentava come l’effettivo mittente della e-mail, ma ne celava la paternità attraverso il meccanismo di funzionamento del worm, il quale si autoreplicava sfruttando gli indirizzi contenuti nella rubrica di Outlook: in tal modo, il destinatario erano indotto a ritenere l’e-mail proveniente da un mittente diverso da quello effettivo, il C., ed a fare affidamento sulla bontà del messaggio ricevuto nel caso ne conoscesse l’apparente autore (dal cui computer veniva inviato il messaggio).

L’abusività della introduzione, oltre che con l’inganno insito nelle modalità di presentazione del primo script, è integrata anche dal sistema occulto con il quale agiva il secondo script, posto che l’abbassamento delle impostazioni di protezione del browser comportava l’esecuzione della seconda parte del codice senza che l’utente ne avesse alcuna consapevolezza.

Le modalità di introduzione descritte rendono pertanto inappropriato il riferimento che la difesa ha ripetutamente fatto al funzionamento di alcuni cd autoinstallanti per la connessione ad internet fornita da infostrada, kataweb ed altri: in tali casi, infatti, l’esecuzione del programma deve essere volontariamente attivata dall’utente mediante l’introduzione del supporto nel terminale e le modifiche apportate dal programma – spesso funzionali al risultato che l’utente si prefigge con la sua installazione – sono da lui immediatamente percepibili.

Come sopra anticipato, deve ritenersi che le introduzioni abusive avvennero in sistemi informatici presidiati da misure di sicurezza, considerato che il programma Vierika era destinato proprio ad abbassare le impostazioni di protezione del browser.

Nelle versioni più diffuse nel 2001, Internet Explorer consentiva di suddividere i siti internet in quattro differenti aree di protezione (internet, intranet locale, siti attendibili e siti con restrizioni) all’interno delle quali era possibile impostare livelli di sicurezza diversi (da alto a basso) [26], in base alla provenienza ed al grado di attendibilità delle informazioni sul Web: quello predefinito dal produttore Microsoft era quello medio.

Il primo script del programma Vierika agiva su queste misure di protezione abbassando al livello minimo le impostazioni di default presenti nell’area Internet, affinché fosse poi possibile, collegandosi alla pagina web presente sul server di Tiscali s.p.a., l’esecuzione del secondo script del programma.

Deve ritenersi che le impostazioni di protezione di Internet Explorer rientrino a pieno titolo nel concetto di misura di sicurezza di cui all’art. 615 ter c.p., poiché, regolando le finestre a comparsa e l’esecuzione automatica di download e contenuti attivi (fra i quali gli script ed i controlli Active X di cui si è parlato nel corso del dibattimento), costituiscono la protezione minima per gli utenti di internet contro l’occulta installazione di cavalli di Troia, spyware, virus, worm, dialer e l’apertura di backdoor (strumenti attraverso i quali, oltre che captare informazioni e dati, si può ottenere il controllo remoto del terminale infettato).

Nella nota depositata all'udienza del 23/6/04 la difesa non nega che le impostazioni di protezione di Internet Explorer abbiano "...dei riflessi, anche molto, rilevanti, sulla sicurezza della navigazione in rete dell'utente..." e che tali parametri consentono di "...scaricare o non scaricare varie tipologie di oggetti...che, contenendo codice eseguibile, potrebbero potenzialmente dare fastidio" (p. 5).

Del resto è sempre la difesa ad avere evidenziato, in sede di perorazione finale, come l'impostazione del massimo livello di protezione impedisca di scaricare persino le patch di aggiornamento di Microsoft: non si vede, pertanto, come si possa negare che tale strumento costituisca la prima basilare difesa – spesso insufficiente – dei fruitori della rete internet.

Né, come rilevato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, è necessario che le misure di sicurezza abbiano un elevato grado di efficacia, rimanendo tali anche nel caso siano facilmente superabili da una persona mediamente esperta, poiché la loro funzione è solo quella di manifestare lo ius excludendi dell'avente diritto (Trib. Torino 7/2/98, Giur. mer. 1998, p. 708; Trib. Torino 4/12/97, Giur. it. 1998, p. 1923), in conformità con il bene giuridico protetto dalla norma, da ravvisarsi nella tutela del domicilio informatico (cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 3065/99, De Vecchis)[27].

Proprio per tale loro funzione, si è ritenuto in dottrina e giurisprudenza che, prescindendo dalla manipolazione, non necessaria, delle misure di sicurezza, integri il reato anche chi abusi per tempi, finalità od aree di accesso delle autorizzazioni dell'avente diritto e che, in tale concetto, possano farsi rientrare anche barriere materiali[28], quali l'esclusiva disponibilità dei locali contenenti il sistema informatico violato.

Sviluppando l'insegnamento di Cass. pen., sez. V., n. 12732/00, Zara, non risulta pertanto peregrino affermare che, poiché l'illecito non si sostanza nell'effrazione dei mezzi di protezione, ma nella violazione delle disposizioni del titolare, l'introduzione nei sistemi informatici mediante strumenti di intrusione o di controllo remoto che sfruttano canali telematici, quando avviene in sistemi di privato ed esclusivo utilizzo custoditi in locali ad accesso riservato, privi di una qualsiasi propaggine pubblica e visibile nella rete internet, deve considerarsi effettuata in violazione della volontà del titolare (sicché, ad esempio, si dovrà accertare l'effettiva esistenza di misure di sicurezza nel caso della abusiva introduzione in una banca dati consultabile on-line, ma non nel caso di introduzione in una utenza informatica domestica utilizzata per soli fini di esplorazione del web).

Nel fatto commesso dal C. devono ravvisarsi le aggravanti previste dall'art. 615 ter secondo comma numeri 2 – 3 c.p., poiché l'introduzione è avvenuta mediante violenza sulle cose ed il programma Vierika ha apportato effetti pregiudizievoli ai sistemi informatici colpiti: sebbene non sia stato fatto un espresso riferimento normativo, deve ritenersi che le aggravanti siano state contestate con la descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione, in particolare nel riferimento al danneggiamento dei programmi ed al pregiudizio del loro corretto funzionamento.

Quanto alla prima aggravante, secondo quanto già esposto in relazione alla fattispecie di cui all'art. 615 quinquies c.p. e tenuto conto della definizione di violenza fornita dal terzo comma dell'art. 392 c.p. per ogni effetto penale, deve ritenersi che l'ingresso abusivo avvenne mediante l'alterazione dell'ordinario funzionamento del browser Internet Explorer, al quale il programma Vierika forniva istruzioni per l'abbassamento del livello di protezione, senza che l'utente impartisse il relativo comando, realizzando così una modificazione delle normali modalità di comportamento del programma che consente l'esplorazione del web.

Quanto alla seconda aggravante, deve rilevarsi che il worm produce alcuni effetti negativi, per quanto di minima entità, sulla memoria del computer e sui tempi di connessione ordinariamente necessari per l'invio e la ricezione della posta elettronica (con eventuale conseguente aggravio di

INTERNATIONAL TRADERS
www.intertraders.eu

spese telefoniche).

Rilevato, inoltre, che la norma non prescrive che il danno debba avere natura esclusivamente patrimoniale, deve osservarsi che il programma produce anche una pregiudizievole veicolazione di informazioni che sono nella disponibilità esclusiva dell'avente diritto: l'invio di una e-mail a tutti gli indirizzi presenti nella rubrica di Outlook, infatti, rende edotto il destinatario di informazioni che l'apparente mittente potrebbe volere non rivelare (quali, ad esempio, la sua avvenuta connessione ad internet; la conoscenza del suo recapito e-mail che il destinatario può ricavare dal messaggio ricevuto[29]; il fatto, che può essere ignoto al destinatario, che il mittente abbia la disponibilità del suo indirizzo e-mail).

Occorre infine osservare che la modifica occulta e stabile dei livelli di protezione del browser, esponeva l'utente al rischio di ulteriori e più gravi infezioni informatiche, poiché, non essendo a conoscenza della modifica apportata e facendo ragionevole affidamento nell'ordinario comportamento del sistema, avrebbe potuto compiere operazioni o visitare siti pericolosi con il nuovo livello di protezione impostato.

Non vanno, inoltre, sottovalutate le eventuali conseguenze a cui sarebbe stato esposto l'utente del computer infettato per avere inconsapevolmente contribuito alla diffusione del worm: l'essere, infatti, additato quale veicolo del contagio avrebbe potuto giustificare l'applicazione nei suoi confronti di misure di contenimento, come, ad esempio, la sospensione della partecipazione a mailinglist o l'inserimento, da parte dei destinatari, nella lista dei mittenti bloccati.

L'elemento soggettivo è integrato dalla intenzionale volontà del C. di introdursi nei sistemi informatici altrui protetti dai sistemi di sicurezza, quale si desume dalla volontaria diffusione del programma da lui creato a tali fini, con la consapevolezza di averlo fatto mediante inganno e clandestinamente.

Quanto alle aggravanti, la volontà della violenza sulle cose discende dall'aver predisposto il codice affinché alterasse il browser per introdursi nei sistemi altrui, mentre per l'aggravante di cui all'art. 615 ter comma secondo n. 3 c.p. sussiste la necessaria rappresentazione della capacità di danneggiamento del sistema correlata agli effetti del programma creato.

Né, come si è già detto con riferimento all'altra fattispecie criminosa, hanno efficacia esimente le arbitrarie opinioni espresse dall'indagato nel corso dell'interrogatorio, secondo cui gli effetti del programma non sarebbero intrusivi.

7. Estraneità del coimputato

Per quanto concerne il coimputato C. S. va accolta la richiesta del P.M. e della difesa di assoluzione per non aver commesso il fatto.

Infatti, dagli atti processuali non emergono indizi gravi di un'attività di concorso nei reati commessi dal fratello, il quale in sede di interrogatorio si è assunto l'esclusiva responsabilità di essi.

In sostanza, l'unico elemento riconducibile a questo imputato è quello, in sé poco concludente e, comunque, da solo inidoneo, dell'intestazione delle utenze telefoniche usate dal fratello per le connessioni.

L'esclusiva assunzione di responsabilità da parte del fratello G., come si è sopra detto, è invece riscontrata sia dalla riferibilità a lui delle operazioni di amministrazione dei due siti internet, sia dal

possesso – che non risulta avere il fratello - delle idonee capacità di programmazione: del resto i programmi sequestrati presso la comune residenza familiare furono trovati nei dischi rigidi presenti nella stanza nella disponibilità esclusiva di G..

È, dunque, attendibile l'affermazione di estraneità ai fatti contestati effettuata dal coimputato C. S. già in sede di perquisizione domiciliare (negativa quanto alla sua stanza) e reiterata in sede di interrogatorio.

8. Trattamento sanzionatorio

Passando all'esame del trattamento sanzionatorio, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., si reputa equa la condanna dell'imputato C. G. alla pena di mesi sei di reclusione così determinati:

- pena base per il reato di cui all'art. 615 ter c.p. - ritenuta la sua maggiore gravità a causa della pena edittale per esso prevista - di mesi tre, in ragione dell'intensità del dolo e delle modalità descritte dell'azione, valutate equivalenti le circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p., applicate a causa della incensuratezza dell'imputato e del comportamento collaborativo tenuto in occasione della perquisizione domiciliare, alle ritenute aggravanti;

- aumentata tale pena base di un mese per la continuazione interna al capo A) e di due mesi ex art. 81 cpv. c.p. a causa della plurima commissione del reato di cui all'art. 615 quinquies c.p., collegato con il vincolo della continuazione - stante la evidente medesimezza del disegno criminoso - alla fattispecie criminosa sopra indicata.

Sussistendo le condizioni di cui agli artt. 53 ss. l. 689/81 e ritenuta la maggiore idoneità della pena sostituiva al reinserimento sociale della imputato, stante la sua estraneità a circuiti delinquenziali, si ritiene di giustizia sostituire la pena detentiva di mesi sei di reclusione, con la pena pecuniaria corrispondente a € 6.840 di multa, avuto riguardo ai criteri di ragguaglio di cui agli artt. 135 cp e 57 l. 689/81 (38 euro per 180 giorni).

Si ravvisa, inoltre, l'opportunità, considerati i criteri di cui all'art. 133 c.p. e l'incensuratezza del C., di concedere il beneficio della non menzione della condanna previsto dall'art. 175 c.p., mentre quello della sospensione condizionale non è stato chiesto nelle subordinate dalla difesa e non corrisponde all'interesse dell'imputato, in ragione delle caratteristiche e dell'entità della pena irrogata.

Visto l'art. 544, 3° comma c.p.p., si indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza, trattandosi di questione nuova in giurisprudenza e che, quindi, richiede particolare cura nella esplicazione della ratio decidendi.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p., dichiara C. G. colpevole del reato continuato ascrittogli e concesse le attenuanti generiche, valutate equivalenti rispetto all'aggravante contestata al più grave reato ex art. 615 ter c.p. in forma aggravata, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione, sostituita ai sensi dell'art. 53 l. 689/81 con la corrispondente pena pecuniaria di € 6.840,00 di multa.

Non menzione ai sensi dell'art. 175 c.p.

INTERNATIONAL TRADERS
www.intertraders.eu

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve C. S. dal reato continuato ascrittogli per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 544 terzo comma c.p.p. indica in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione

Bologna, 21/7/2005.

Il Giudice
Dott. Pier Luigi di Bari

[1] Pag. 6 ss.

[2] Pag. 16 ss.

[3] Si veda altresì il riferimento che a p. 3 dell'analisi tecnica redatta dal M.llo F. viene fatto alla circostanza che le conclusioni a cui pervenne la G.d.F. sul meccanismo di funzionamento del programma, trovarono conferma nelle corrispondenti analisi effettuate dalla società F-Secure Corp.

[4] Vierika è il nome di una ragazza che l'imputato ha conosciuto nella città ucraina di Krivoj Rog ed alla quale ha dedicato il sito digilander.iol.it/vierika: cfr. verbale di interrogatorio e teste F., p. 91.

[5]In particolare con i seguenti comandi: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\StartPage","http://web.tiscalinet.it/krivojrog/vierika/Vindex.html" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\1201", 0 , "REG_DWORD"

[6] Come accertato anche dal servizio di sicurezza informatica di Tiscali s.p.a., che provvedette ad oscurare il sito il 5 marzo 2001: cfr. teste B., p. 68-69.

[7] Dalle deposizioni del Cap. R. e del M.llo F. si evince che le versioni circolanti in internet del programma Vierika erano in realtà due: poiché una versione utilizzava per la diffusione del secondo script uno spazio web presente sul server di Geocities, provider estero, la p.g. non ritenne opportuno estendere le indagini anche a tale programma. Come si ricava dall'all. 1 della nota di p.g. del 28/3/01, nel computer dell'imputato vennero rinvenute anche le istruzioni contenute nelle pagine html relative a questa versione (Vindex2.html).

[8] Sul quale, peraltro, non venne rinvenuto il secondo script del programma.

[9] Teste Resetti, p. 5.

[10] Nota di p.g. della G.d.F. di Milano del 19 marzo 2001, p. 2.

[11] Teste B., p. 55; verbale di esibizione e sequestro G.d.F. Cagliari del 14/3/01.

[12] Questa connessione ha la durata di circa h. 2,30. La connessione del 3 marzo risulta sia dai dati estrapolati dalla p.g. dai cd sequestrati presso il provider e contenenti i log di amministrazione e navigazione del sito (dei quali vengono riportate due stringhe nella nota di p.g. del 19/3/01 a p. 2), sia dalla successiva comunicazione fatta dalla B. alla G.d.F. di Milano in esecuzione del decreto di esibizione e sequestro della Procura di Milano.

[13] Il nickname completo di C. G. è Krivoj Rog, nome della cittadina ucraina dalla quale proviene sua moglie; tale termine si rinviene anche nel url di un sito che l'imputato, in sede di interrogatorio, ha dichiarato di amministrare (web.tiscali.it/krivoj).

[14] Testi Cap. R., p. 12; M.llo M., p. 75, 79, 86; F., p. 45, 77 ss.

[15] Teste F., p. 22.

[16] Sullo spazio web di tale provider la p.g. riteneva che avrebbe potuto essere inserita la seconda parte del codice del worm: tra i programmi successivamente sequestrati, rinvenuti nel pc dell'imputato, ve ne erano nove contenenti il comando diretto ad impostare come start page del browser il sito digilander.iol.it/vierika.

[17] Cfr. note Polizia Tributaria della Lombardia del 13 e del 19 marzo 2001; per la constatazione che la prima descrizione del funzionamento del programma era conforme con i risultati della successiva analisi tecnica cfr. teste F. p. 25.

[18] Si noti che le immagini utilizzate nella prima nota di p.g. del 13/03/01 sono state tratte da materiale della società di sicurezza informatica F-Secure Corp., come si desume dal copyright delle stesse immagini.

[19] L'e-mail contenente il worm venne ricevuta anche dalla G.d.F. di Milano: cfr. teste F., p. 6.

[20] Si fa riferimento all'all. 1 alla nota di p.g. del 28 marzo 2001.

[21] Teste Cap. R., p. 4-5; teste F., p. 89, teste B., p. 68, per quanto concerne la segnalazione che la società F-Secure Corp. fece a Tiscali s.p.a.. La stessa difesa dà atto nella nota difensiva dep. all'udienza del 23/6/04 (p. 12) che "la diffusione registrata del worm Vierika, secondo una fonte non smentita, ma anzi citata dal M.O. F. stesso, è arrivata a circa 1500 infezioni nell'arco di 24 ore" e che "sia F-Secure Corporation, sia Symbolic s.p.a. hanno dichiarato che è stato il loro intervento a consentire il blocco del worm..." (p. 16), che evidentemente doveva essersi diffuso.

[22] Teste B., p. 68; verbale di esibizione e sequestro G.d.F. Cagliari del 14/3/01.

[23] Teste F., p. 51-53.

[24] Teste F., p. 31.

[25] Nota di p.g. G.d.F. Milano del 15/5/01, p. 5.

[26] Teste F., p. 55.

[27] Suggestiva è, peraltro, l'impostazione dottrinale che, accostando la fattispecie in esame al reato di cui all'art. 637 c.p., piuttosto che alla violazione di domicilio, ravvisa il bene giuridico protetto nella integrità e nel diritto alla esclusiva fruizione dei sistemi informatici.

[28] Trib. Torino 4/12/97, cit., dove si fa riferimento alla sistemazione dell'impianto in un locale munito di serrature; accenna alle misure di protezione esterne al sistema anche Trib. Gorizia 19/02/03, Riv. pen. 2003, p. 891. Cfr. Relazione ministeriale alla legge n. 547 del 1993, che ha introdotto nel codice penale gli artt. 615 ter e ss., secondo cui "dovendosi tutelare il diritto di uno specifico soggetto, è necessario che quest'ultimo abbia dimostrato, con la predisposizione di mezzi di protezione sia logica che fisica (materiale o personale) di voler espressamente riservare l'acceso e

INTERNATIONAL TRADERS
www.intertraders.eu

la permanenza nel sistema alle sole persone da lui autorizzate".

[29] Non è un caso che l'Autorità Garante della Privacy abbia statuito nel 2001 e nel 2003 che gli indirizzi e-mail, attenendo alla sfera di riservatezza individuale, non sono di pubblico dominio e che, senza il consenso del destinatario, non deve considerarsi lecita l'attività di spamming.

INTERNATIONAL TRADERS
www.intertraders.eu

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE SECONDA PENALE

composta dai magistrati:
1 - Dr. Guarino Salvatore PRESIDENTE
2 - Dr. Ricchi Jolanda CONSIGLIERE
3 - Dr.Pasquariello Domenico CONSIGLIERE

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza odierna dal consigliere relatore Dr. Pasquariello Domenico
Inteso l'appellante
Inteso il Procuratore Generale, dr. Posini
ed i difensori, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale
CONTRO
XXXX
nato a XXXX
con domicilio dichiarato: XXXXXXXX

agli artt. 110 c.p.. 615 ter e quinquies ep, 81 cpv, poiché in concorso tra loro, creando un "virus" (programma atto a danneggiare sistemi informatici) denominato "Vierika" trasmesso in via informatica al provider "Tiscali" e tramite questo a circa 900 utilizzatori del provider, si introducevano nei sistemi informatici di tali utenti e acquisivano dati anche riservati contenuti nei loro personal computers -tra i quali indirizzari e-mail- a loro insaputa, inoltre per mezzo del virus danneggiavano i programmi contenuti nei personal computers e ne pregiudicavano il corretto funzionamento.

In Bologna l'imputato: XXXX

avverso la sentenza emessa dal TRIBUNALE MONOC. di BOLOGNA in data 21/07/2005 che ha pronunciato il seguente dispositivo:

Visti artt. c.p.p., dichiara XXXX colpevole del reato continuato ascrittogli e concesse le attenuanti generiche, valutate equivalenti rispetto all'aggravante contestata al più grave reato ex art 615 ter c.p. in forma aggravata, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione, sostituita ai sensi dell'art. 53 L. 689/81 con la corrispondente pena pecuniaria di euro 6.840,00 di multa. Non menzione ai sensi dell'art. 1 c.p. Visto l'art. 544 terzo comma c.p.p. indica in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

INTERNATIONAL TRADERS
www.intertraders.eu

MOTIVAZIONE

Sentenza impugnata.

Con sentenza n. 1823 del 21.7.0S il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, ha giudicato XXXXX e YYYYY per i delitti p. e p. dagli artt 615 ter e 61S quinquies c.p.

Secondo l'imputazione essi avevano creato un cosiddetto "virus", cioè un programma dall'unica funzione di introdursi e danneggiare sistemi informatici, da loro chiamato "Vierika", e l'avevano trasmesso in via informatica al provider "Tiscali"; attraverso questo il virus si era introdotto nei sistemi di circa 900 utenti, acquisendo dati riservati nei relativi personal computers, danneggiandone i programmi e pregiudicandone il corretto funzionamento; in Bologna "nel corso del 2001".

Nell'accertamento compiuto in sentenza "Vierika" è un "internet worm" programmato in Visual Basic Script, i cui effetti derivano dalla integrazione di due script differenti (gli script sono stringhe di comandi, ed il visual basic è un linguaggio di programmazione).

Il primo script (la prima parte del virus) era inviato come attachment ad una email, dall'oggetto "Vierika is here", cui era appunto allegato il file "infettante" Vierika.jpg.vbs; nella mail ricevuta dal destinatario appariva però solo il nome Vierika.jpg, dall'estensione (".jpg") ingannevole in quanto caratterizzante files di immagini.

Il destinatario della mail, accettando l'allegato, mascherato con il nome che suggeriva l'immagine di Vierika, installava invece a sua insaputa nel proprio computer il file Vierika.jpg.vbs.

Questo era in realtà un file di programma, che agiva sul registro di configurazione del sistema Windows (di massiccia diffusione, come è noto), riconfigurando al livello minimo di protezione il browser Internet Explorer ed inserendo come home page predefinita la pagina web con indirizzo http://vveb.tiscalinet.it/krivojrog/vierika/Vindex.httlll.

Il secondo script in Visual basic (la seconda parte del virus) era costituito dal suddetto documento Vindex.html; l'utente, avviando la navigazione in Internet, veniva inviato al suddetto indirizzo, automaticamente apriva il documento e "scaricava" quella che era invece una stringa di comandi.

Per effetto di questo secondo script nel disco rigido dell'utente veniva creata una specifica partizione, in cui veniva annidata la prima parte del codice virale; successivamente, sempre in maniera occulta, il programma installato produceva un comando di mass-mailing, inviando a tutti gli indirizzi del sistema di posta elettronica Outlook una e-mail contenente l'allegato virale Vierika.jpg.vbs, con diffusione esponenziale del virus ed effetto autoreplicante.

A questo accertamento si era arrivati in quanto l'email virale "Vierika is here", contenente l'allegato suddescritto Vierika.jpg.vbs, era arrivata anche ad un indirizzo in uso alla Guardia di Finanza di Milano.
Le indagini erano proseguite attraverso l'acquisizione di documenti riepilogativi di tracce informatiche conservate nel server del gestore Tiscali, che dimostravano che XXXX, di professione consulente informatico, con il nick name "Krivoj" con il quale egli si era registrato presso detto provider, era l'amministratore (cioè colui che aveva creato e gestito) del sito con indirizzo http://web.tiscalinet.it/krivojrog/vierika/Vindex.html contenente la seconda scritta del programma virale.
Nel corso di perquisizione e sequestro presso l'abitazione dei fratelli XXXX e YYYYY (il secondo era risultato essere l'intestatario dell'utenza telefonica usata per i collegamenti al web) il primo riconobbe di essere il creatore di "Vierika" (come del resto fece in seguito in sede di esame) e collaborò con la polizia giudiziaria, indicando egli stesso i files di programmazione di Vierika contenuti nel disco rigido del proprio personal computer, e masterizzandone copie, che erano sottoposte a sequestro.

Il suddetto meccanismo di funzionamento del virus Vierika, i cui files di programmazione sono stati

INTERNATIONAL TRADERS
www.intertraders.eu

così acquisiti agli atti, è stato riportato in sede dibattimentale dal M.llo Forte, all'epoca dei fatti in servizio presso il Nucleo Crimini Informatici della GdF Milano.

Il giudice ha ritenuto esaustive le risultanze probatorie così sommariamente ora riassunte, senza ravvisare la necessità di accertamenti peritali, richiesti dalla difesa sin dalla fase predibattimentale, ed esplicati con memoria tecnica prodotta all'udienza del 23.6.04, giacché sostanzialmente la stessa difesa non aveva messo in discussione il funzionamento del programma come sopra descritto, ma ne aveva offerto in definitiva una lettura non penalmente rilevante.

Per altro profilo la sentenza di primo grado motivatamente si discostava da certo orientamento di legittimità che proprio in materia pare indicare necessaria la perizia, in ragione dell'accertamento di natura tecnica imprescindibile per la ricognizione delle fattispecie dei "computer's crimes". Pertanto il Tribunale di Bologna, accertata la materiale estraneità ai fatti di YYYYY, riteneva il coimputato XXXXX responsabile di entrambi i reati a lui ascritti, con l'aggravante -ritenuta di fatto esplicitata nell'imputazione- di cui all'art. 615 ter, c.2 nn. 2 e 3) (violenza sulle cose e danneggiamento del sistema o dei suoi dati, od alterazione parziale di funzionamento), che comporta la procedibilità d'ufficio.

Quanto al reato p. e p. dall'art. 615 ter c.p., il counter del sito http://web.tiscalinet.it/krivojrog/vierika/Vindex.html aveva registrato 829 visite, che corrispondevano ad altrettante pregresse installazioni della prima stringa di Vierika, altrettante abusive introduzioni in sistemi informativi dei personal computers di utenti, altrettante elusioni di sistemi di protezione ed altrettante "infezioni", con correlativa integrazione della fattispecie in contestazione.
Le aggravanti erano ravvisate integrate dalla alterazione dell'ordinario funzionamento del browser Explorer, integrante violenza sulle cose, e dagli effetti di allungamento dei tempi di connessione, con aggravio di spese telefoniche, per effetto dell'occulto mass mailing, nonché dal danno non patrimoniale della veicolazione di informazioni private (invio agli utenti in rubrica) e dell'apparire mittente di mail con allegati virali, integranti danneggiamento di sistema e di dati.

Quanto al reato p. e p. dall'art. 615 quinquies c.p. Vierika, inizialmente inviato dall'imputato -per sua espressa ammissione- ad alcuni indirizzi di posta elettronica reperiti sulla bacheca virtuale del sito www.sexualcyber.com alterava la funzionalità telematica del sistema infettato, per effetto della alterazione dei parametri di protezione del browser, all'oscuro dell'utente, e dell'invio automatico e massiccio di email, con ciò integrandosi anche detta fattispecie.

Per tali motivi il giudice irrogava la pena di mesi sei di reclusione, previa:

- concessione di attuanti generiche in valutazione di equivalenza con le aggravanti ad effetto speciale;
- pena base di mesi tre di reclusione per il reato art. 615 ter;
- aumento di pena ex art. 81 cpv c.p. di mesi uno per la continuazione interna e di mesi due per la plurima commissione del reato concorrente.

La pena veniva sostituita con la sanzione pecuniaria nella misura corrispondente ex art. 53 L. 689\81, con il beneficio della non menzione.

Motivi d'appello.

Il difensore di XXXXX ha proposto appello, eccependo, con il primo motivo, la nullità del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza della imputazione, in ragione della omessa indicazione delle identità delle 900 presunte parti offese, nonché della descrizione "cumulativa" della condotta, effettuata con riferimento a due diverse norme incriminatici, e con la conseguente incertezza circa la riferibilità del fatto ad una specifica norma di legge asserita violata.

Con secondo motivo è stata impugnata 1'ordinanza, resa all'udienza 27.11.03, di diniego di

INTERNATIONAL TRADERS
www.intertraders.eu

pronuncia ex art. 129 c.p.p. sulla richiesta di declaratoria di improcedibilità per difetto di querela in relazione al reato di cui all'art. 615 ter c.p., contestato espressamente non aggravato.

Con il terzo motivo è stata dedotta l'inutilizzabilità di annotazioni di servizio della GdF, costituenti nella sostanza accertamenti tecnici ripetibili.

Con il quarto motivo sono stati denunciati il percorso motivazionale della sentenza impugnata, viziato da ricostruzione tecnico informatica priva di fondamento peritale, ed il correlativo ingiustificato diniego dell'espletamento di perizie, chieste dalla difesa, sulle modalità di generazione e conservazione dei log (registri di collegamento), acquisiti presso il gestore Tiscali ed Infostrada, nonché sull'originale del codice sorgente del software per cui è causa.

Con il quinto motivo, connesso ed in parte reiterativo del precedente, si è protestata la imprescindibilità per l'accertamento dei fatti e per la decisione dell'espletamento delle perizie suddette, che avrebbero permesso altresì di verificare le tesi difensive sull'effettivo funzionamento del software, e su quali fossero gli applicativi (ad esempio Outlook, e non il più diffuso Outlook Express) con i quali Vierika era in grado di interagire, nonché sulla integrità dei dati telematici raccolti nel corso delle indagini.

Con il sesto motivo si è argomentato che la condotta, pur nella denegata ricostruzione dei fatti operata in sentenza, non integra il reato di cui all'art. 615 ter c.p..

Secondo la prospettazione difensiva infatti non è ravvisabile il requisito essenziale del reato 615 ter, costituito dall'accesso al sistema dell'utenza, giacché realizzato dal programma, ma non da XXXXX, nel senso che questi rimaneva all'oscuro degli utenti, dei computers che scaricavano il programma e dei dati in essi contenuti.

Altro elemento caratterizzante la fattispecie incriminatrice, e non integrato, è costituito dall'assenza di elusione di misure di sicurezza informatiche, tali non potendo definirsi semplici opzioni di configurazione di un applicativo.

Con il settimo motivo si è dedotta l'assenza di prova circa la effettiva introduzione nei sistemi delle pretese 900 parti offese, nessuno dei quali era stato individuato ed esaminato. Con l'ottavo motivo è stata dedotta l'insussistenza delle aggravanti; il programma Vierika, che è semplicemente autoreplicante, non provoca alcuno degli eventi richiesti per la sussistenza delle aggravanti, quali alterazioni, danneggiamenti o distruzioni di programmi informatici.

Esso si installa e si diffonde, senz'altro risultato che questo, ricercato per motivi di studio dall'appellante, programmatore di professione; la corretta terminologia informatica intende per modificazione (posto che la distruzione non è in questione) di un programma l'accesso ai codici sorgente del programma per l'alterazione del funzionamento.

Nessun pregiudizio, o variazione, di funzionamento era inoltre percepibile dall'utente.

Con il nono motivo, attinente la fattispecie di cui all'art. 615 quinquies c.p., sono state richiamate le precedenti argomentazioni, rilevanti anche per escludere la sussistenza del danneggiamento, o dell'alterazione di funzionamento, dei sistemi, dati o programmi, richiesti dalla norma incriminatrice.

Vierika insomma non era stato progettato per danneggiare, ed era stato scritto proprio nella consapevolezza della innocuità, il che anche si rifletteva sull'elemento soggettivo del reato.

Con il decimo motivo è stata dedotta la non correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, in violazione del disposto dell'art. 521 c.p.p., in quanto la prima condotta di ritenuta diffusione del preteso virus, attraverso la posta elettronica, era del tutto assente nella contestazione.

Per tali motivi l'appellante ha chiesto:

- in via principale l'assoluzione con la miglior formula;
- in gradato subordine:

INTERNATIONAL TRADERS
www.intertraders.eu

- declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio;
- nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 521 c.p.p.;
- rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con espletamento di perizie;
- declaratoria di improcedibilità per il reato di cui all'art. 615 ter c.p.p. per difetto di querela, e rideterminazione della pena, ferme la sua conversione e la non menzione.

DECISIONE DELLA CORTE

All'esito dell'odierna udienza, svoltasi in contumacia dell'imputato XXXXX, pronunciando sulle conclusioni delle parti che sono trascritte in epigrafe la Corte ha deliberato la presente sentenza di parziale riforma della sentenza impugnata.

Nullità del decreto di citazione a giudizio, dedotta violazione dell'art. 521 c.p.p.

L'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio è fondata sui rilievi della mancata indicazione dell'identità delle parti offese e della descrizione "cumulativa" della condotta incriminata.
In proposito si deve ritenere che nella descrizione della condotta incriminata, come esplicitata nella imputazione, nessun equivoco sul fatto storico contestato o sulle norme di legge violate, né alcuna indeterminatezza nella imputazione, né alcuna vulnerazione della possibilità di comprendere l'accusa e di adeguatamente potersi difendere, è dato rinvenire.

Avuto riguardo alla specificità del reato in esame, in danno di un numero indiscriminato e potenzialmente esponenziale di soggetti (suscettibile di cosiddetto danno diffuso), l'indicazione delle generalità, anziché del solo numero complessivo delle parti lese, è del tutto irrilevante ai fini defensionali e di comprensione dell'oggetto del giudizio penale circoscritto dalla contestazione, elementi questi di esauriente rilievo per valutare la nullità dell'atto, secondo quanto disposto dall'art. 429, c.1 lett. c), e c.3, c.p.p.

Identiche considerazioni si impongono in relazione alla censura della descrizione cumulativa, e riferita a due norme incriminatici, della condotta, stante il parziale concorso formale (ovvero coincidenza in fatto degli elementi costitutivi essenziali previsti dalle fattispecie astratte). L'eccezione di nullità del decreto di citazione in giudizio va pertanto disattesa. Parimenti non è ravvisabile alcuna violazione della necessaria correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza; nella prospettazione dell'appellante ciò sarebbe dovuto alla mancata esplicitazione, nella imputazione, dell'invio in rete della e-mail con l'allegato contenente la prima parte di Vierika.

Si ritiene di osservare, in proposito, che ciò invero attiene ad elementi di dettaglio della condotta non riferibili ad elementi costitutivi essenziali delle fattispecie incriminatici (condotta di abusivo accesso a sistema informatico, elusione di misure di protezione, diffusione di programma avente determinati scopi od effetti vietati), in ordine ai quali debba esser condotto il giudizio di corrispondenza imposto dall'art. 512 c.p.p.

Sull'accertamento istruttorio.

Nel corso del dibattimento di primo grado (udienza 23.9.04) con l'accordo delle parti, sono state acquisite ex art. 493, c.3, c.p.p., e dichiarate utilizzabili per la decisione le annotazioni di polizia giudiziaria (Guardia di Finanza) del 13.3.01, 19.3.01, 28.3.01, 15.5.01.
Già il rilievo dell'acquisizione con dichiarazione di utilizzabilità, avvenuta con l'espresso consenso della difesa, è esaustivo della infondatezza dei motivi di impugnazione in proposito, relativi alla natura di accertamento tecnico non ripetibile delle annotazioni.

INTERNATIONAL TRADERS
www.intertraders.eu

Va aggiunto che, comunque, l'attività di accertamento compiuta è stata ripercorsa, con analogo risultato di acquisizione di fonti di conoscenza del fatto, nel corso delle deposizioni testimoniali degli ufficiali di polizia giudiziaria D. Rasetti, G. De Filippo, G. Mazzaraco (udienza 27.11.03), D. Forte e di C. Broi, responsabile di Tiscali SpA per i rapporti con l'autorità giudiziaria (udienza 27.5.04).
Anche dalle suddette deposizioni risulta univocamente ricostruibile, nel termini descritti nella sentenza impugnata e sopra riportati, il funzionamento del programma informatico "Vierika"; è d'obbligo rilevare che si è trattato di testimoni (ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti al Nucleo Crimini Informatici, forniti di specifica preparazione e formazione in materia informatica) che, in forza della ricordata particolare preparazione tecnica, hanno risposto su fatti e circostanze concernenti la loro attività professionale d'indagine.

In tema di prova testimoniale, va aggiunto, il divieto di esprimere apprezzamenti personali non vlge qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata, in conseguenza della preparazione professionale, quando i fatti in ordine ai quali viene esaminato siano inerenti alla sua attività, in quanto, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto, dal momento che quest'ultimo è stato necessariamente percepito attraverso il "filtro" delle conoscenze tecniche e professionali del teste (vedi Casso n. 12942 de116/01/2007).

Pertanto sia le annotazioni di polizia giudiziaria, anche nelle parti relative ad accertamenti ripetibili, per effetto del ricordato consenso dibattimentale, e sia le deposizioni sono pienamente utilizzabili quali fonti di conoscenza per la decisione.

Altra questione è, all'evidenza, costituita dalla esaustività ed attendibilità di dette fonti di conoscenza, questione connessa alla dedotta necessità di accertamento peritale, negato dal giudice di prime cure.

Anche in proposito i motivi d'appello non paiono fondati.

La prima questione è relativa alla "correttezza" della acquisizione delle cosiddette "tracce informatiche" o delle prove documentali di natura informatica.

In proposito è necessario previamente precisare, richiamando espressamente quanto esattamente osservato nella sentenza impugnata, che non è compito del giudicante determinare una sorta di protocollo delle procedure informatiche forensi, ma solo verificare se nella fattispecie l'acquisizione probatoria sia fidefaciente, o se abbia subito alterazioni.

E nella specie, quanto alla tracce informatiche, i dati consegnati alla polizia giudiziaria dal provider Tiscali, relativi agli interventi di manutenzione ed amministrazione del sito con indirizzo http://web.tiscalinetit/krivojrog/vierika/Vindex.html ed alla individuazione dell'utente con username "Krivoj" sono stati confermati dalle dichiarazioni dello stesso XXXXX.

Questi ha espressamente e correttamente riconosciuto (vedi verbale esame delegato del 7.9.01) di aver realizzato "Vierika", di averlo diffuso, di aver creato il sito web con il nome "Krivoj". Non si vede come possa esser messa in dubbio la fidefacienza di una risultanza documentale (tale è la traccia telematica, seppur necessitante di appositi strumenti per la fruibilità), coincidente con le ammissioni dello stesso imputato.

Identica considerazione va svolta in relazione alla prova costituita dal sequestro informatico eseguito presso l'abitazione di XXXXX; come ricordato nella circostanza fu questi stesso -così evitando il sequestro dell'hardware- ad indicare alla polizia giudiziaria i files dì programma rilevanti per l'accertamento, masterizzandone la copia ora in atti.

I rilievi mossi alla metodologia del sequestro informatico peraltro mai sono stati attinenti all'effettivo funzionamento e scopo del programma "Vierika", come accertato nella sentenza impugnata e sopra ripercorso, in realtà mai messi in discussione, neppure nelle memorie "tecniche" depositate dalla difesa; in esse, e del pari nei motivi di appello, mai è allegato o prospettato un funzionamento del programma diverso da quello sopra descritto. Le stesse richieste di perizia

INTERNATIONAL TRADERS
www.intertraders.eu

attengono ad aspetti non rilevanti per l'accertamento del funzionamento di Vierika, quali le modalità di generazione e conservazione dei log (registri di collegamento), acquisiti presso il gestore Tiscali ed Infostrada (rilevanti per individuare le generalità di "Krivoj", fatto non in discussione, od il numero di accessi al sito infettante), ovvero concernono l'originale del codice sorgente del programma e pertanto (atteso che esso era nel 2001 nella memoria del computer dell'imputato) non più espletabili, oltre che non necessarie.

Nel difetto di effettive necessità istruttorie -secondo il parametro dell'assoluta necessità richiesto dall' art. 507 c.p.p.- volte a colmare lacune o contraddizioni nell'accertamento dei fatti, va confermata l'ordinanza del Tribunale di rigetto della richiesta di integrazione probatoria; per i medesimi motivi, riportati anche al disposto dell'art. 603 c.p.p., va disattesa la richiesta di assunzione della prova nel giudizio di appello.

Reato di cui all'art. 615 ter c.p.

La norma, come è noto, è posta a tutela del cosiddetto "domicilio informatico", inteso sia come spazio fisico in cui sono contenuti dati informatici personali, sia quale spazio ideale di pertinenza della sfera individuale e privata.

L'accertamento istruttorio condotto nel giudizio di primo grado offre piena contezza di come XXXXX, creando il programma "Vierika" e poi diffondendolo occultamente per mezzo di mass mailing e del sito web ….....Vindex.html, secondo il meccanismo sopra descritto, abbia integrato il reato in contestazione.

In proposito vanno richiamate le puntuali osservazioni svolte nella sentenza impugnata, relative alla sussistenza degli elementi costitutivi e tipizzanti del delitto di accesso abusivo a sistema infonnatico.
In primo luogo si pongono indubbie la materialità dell'accesso attraverso il worm "Vierika" e la diffusione indiscriminata del medesimo.

Esse sono state provate dalle deposizioni citate Broi, Rasetti e Forte, in merito alle segnalazioni sulla diffusione del virus effettuate da alcune società di informatica (F-Secure Corporation, Symbolic SpA), alle lamentele pervenute al provider Tiscali poiché il programma era annidato sugli spazi web da esso gestiti, nonché dal counter del sito http://web.tiscalinet.it/krivojrog/vierika/Vindex.html dal quale risultavano 829 accessi (vedi annotazione GdF 13.3.01); agli accessi corrispondono necessariamente altrettante ricezioni della mnail "Vierika is here", altrettante installazioni automatiche, immediate ed occulte degli script contenuti nell'attachment alla mail, altrettante occulte riconfigurazioni di registro di Windows, altrettante involontarie ed indesiderate "navigazioni" al sito suddetto, scaricando il secondo script di programma.

Tale meccanismo ha indubbiamente il carattere dell'abusività richiesto dalla norma incriminatrice, ravvisabile prima nella fraudolenta induzione in errore dell'utente che riceveva la mail "Vierika is here", ingannato dall'estensione ".jpg" dell'attachment, che indicava un file immagine, il quale conteneva invece la prima stringa di comandi, e poi nel sistema occulto di scarico del secondo script, realizzato attraverso la riconfigurazione occulta della protezione, e la reimpostazione della home page del browser, il tutto sempre all' insaputa dell'utente.

Sempre all'insaputa dell'utente, e contro la sua volontà, il programma "clandestino" insediato nel sistema informatico provvedeva ad inviare a tutti gli indirizzi della rubrica della posta elettronica (se gestita con l'applicativo "Outlook", peraltro di larga diffusione) l'email con l'allegato vitale Vierika.jps.vbs, con il cosiddetto effetto autoreplicante.

Prova ne sia che, in brevissimo tempo, dall'invio da parte di XXXXX della mail virale a pochi indirizzi trovati sulla bacheca virtuale del sito sexualcyber.com (come da quegli riconosciuto), il sito "trappola" ….Vindex.html era stato involontariamente aperto da oltre 800 utenti "infettati" del

INTERNATIONAL TRADERS
www.intertraders.eu

provider Tiscal (si aggiunga che la mail virale, presumibilmente, era stata ricevuta da un numero molto maggiore di indirizzi e sistemi informatici).

L'appellante deduce che, anche nella denegata ipotesi d'accusa, nel descritto funzionamento, autoreplicante ma non "virale", non sarebbe ravvisabile requisito essenziale del reato 615 ter, costituito dall'accesso al sistema dell'utenza, giacché comunque XXXXX, stante l'effetto autoreplicante automatico, rimaneva ignaro degli indizi informatici raggiunti e dei dati contenuti nelle memorie dei computers che scaricavano il programma.

L'argomento è di particolare rilievo.

La Corte non ritiene che la norma incriminatrice, posta come premesso a tutela del domicilio informatico, possa essere interpretata con tale effetto riduttivo di tutela; la lettera dell'art. 615 ter infatti richiede unicamente l'abusività dell'accesso al sistema, ovvero la permanenza contro lo jus prohibendi del titolare, ma non pretende l'effettiva conoscenza, da parte dell'agente, dei dati protetti.
Avuto riguardo alle specificità dei sistemi informatici e delle trasmissioni telematiche, che consentono la manipolazione e l'uso di un enorme numero di dati senza la diretta interlocuzione con ognuno di essi da parte dell'agente, introdurre in via interpretativa l'ulteriore requisito della conoscenza effettiva dei dati manipolati, a corredo esplicativo della nozione di "accesso abusivo", equivarrebbe ad una sostanziale vanificazione della ratio incriminante.

Nella fattispecie le modalità dell'azione (ovvero la creazione del programma autoreplicante ed il suo "lancio" nel web) erano univocamente dirette ad inviare ed installare occultamente e fraudolentemente il programma, di cui XXXXX ha ammesso la paternità, ad una comunità indiscriminata ed inconsapevole di utenti, usandone i dati personali della rubrica di posta. Ciò appare sufficiente per integrare la nozione di "accesso abusivo" penalmente rilevante, giacché è nel prelievo indesiderato dei dati personali dal domicilio informatico che va individuato il vero bene personalissimo protetto dalla norma, e non tanto nella conoscenza o conoscibilità di quelli da parte del soggetto agente.

In altri termini alla specificità dei sistemi informatici, che consentono l'uso di dati senza la "conoscenza" di essi, come tradizionalmente intesa, da parte dell'operatore, va correlata l'interpretazione della nozione di accesso posta dalla norma incriminante.
Nella prospettazione difensiva dell'appellante altro elemento caratterizzante la fattispecie incriminatrice, e non integrato, è costituito dall'assenza di elusione di misure di sicurezza informatiche, tali non potendo definirsi semplici opzioni di configurazione di un applicativo. In proposito si presentano totalmente condivisibili, ad avviso della Corte, le valutazioni svolte dal giudice di prime cure (pag. 18 della sentenza impugnata), da richiamarsi integralmente.
Come detto il programma Vierika, per potersi installare, modificava occultamente (con il primo script di comandi) le impostazioni di protezione di Internet Explorer; ciò non è posto in discussione dalla difesa, che le qualifica piuttosto come opzioni di configurazione del sistema.
Nella sostanza le "impostazioni di protezione" regolano l'esecuzione automatica di download e contenuti attivi durante la navigazione Internet, permettendo di configurare diversi livelli di protezione, con richiesta o meno di conferma da parte dell'utente e con eventuali barriere automatiche per determinati programmi o contenuti attivi.

Esse quindi non possono che rientrare nella nozione di "misure di sicurezza" a protezione del sistema; misure elementari, facilmente aggirabili, già predisposte nell'applicativo, ma comunque qualificabili misure di protezione, giacché esse attinenti esclusivamente non alla configurazione di Explorer (modalità di fruizione) ma alla maggiore o minore interazione passiva del sistema informatico, connesso al web, dall'esterno verso il suo interno.

Va pertanto confermato il giudizio di sussistenza del reato in esame, condotto nella sentenza impugnata.

La Corte ritiene peraltro fondati i motivi gradati di appello, relativi alla insussistenza delle

INTERNATIONAL TRADERS
www.intertraders.eu

aggravanti ritenute -in motivazione, giacché l'imputazione è priva di espressa contestazione ed il dispositivo fa riferimento ad una sola aggravante- dal giudice monocratico del Tribunale. Queste, pur non richiamate attraverso specifica indicazione delle norme di legge violate, sono state valutate contestate in fatto nel riferimento espresso, contenuto nella descrizione della condotta incriminata, "danneggiamento di programmi" ed al "pregiudizio per il corretto funzionamento" degli stessi (integranti le previsioni poste ai nn. 2 e 3 del comma 2 dell'art. 615 ter c.p.).

Invero non è ravvisabile, nelle modalità di installazione e di funzionamento del worm Vierika, in primo luogo alcun "danneggiamento" dei programmi del sistema dell'utente, né alcuna "modificazione" in senso informatico.

Quelli, infatti, anche dopo l'installazione occulta di Vierika, rimanevano perfettamente operativi, come in precedenza, con le stesse caratteristiche di fruizione e di scopi, senza alcuna modificazione di dati, ambiente, interazione, programma; in effetti Vierika si limitava ad usare occultamente i suddetti programmi (in particolare gli applicativi di navigazione web Explorer e di posta elettronica Outlook) ed i dati della rubrica di posta elettronica, senza alcuna modificazione (ovvero diversa quali non era stato progettato; data la duttilità e versatilità funzionale dei programmi applicativi più diffusi, deve invece ritenersi che "alterare" un programma significhi anche manipolarlo in modo che compia azioni non volute dall'utente, ovvero modificarne i parametri di funzionamento, anche secondo opzioni e possibilità previste nel programma stesso, contro la volontà dell'utilizzatore.

Ciò è quanto ha realizzato, diffusamente, il programma Vierika.

Non altrimenti che alterazione è definibile l'azione occulta ed indesiderata di modificazione del registro di di Windows, attraverso i comandi di programma Vierika "HKEY_CURRENT_USER" etc, che modificavano l'home page predefinita del browser, ed abbassando al livello minimo le protezioni; non altrimenti che alterazione di funzionamento sono definibili il comando e l'azione occulte di mass mailing.

Per conseguenza ne deriva compiutamente integrata la fattispecie delineata e punita dall'art. 615 quinquies c.p., e per tale parte va confermata la sentenza di condanna di primo grado.

Per effetto della parziale riforma del giudizio di condanna va rideterminata la pena da infliggersi all'appellante.

Tenuti fermi il riconoscimento delle attenuanti generiche, la sostituzione della pena detentiva ex art. 53 L. 689\81 e la concessione del beneficio della non menzione della condanna, si reputa equo ed adeguato determinare la pena in mesi due di reclusione ed euro 2000 di multa (pena base di mesi tre ed euro 3.000), con pena detentiva sostituita con la pena pecuniaria corrispondente di Euro 2.280 di multa.

Titolo di reato e data di commissione consentono di condonare la pena ex L. 241\06. Nel resto va confermata la sentenza appellata.

PQM

Visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza del Tribunale Monocratico di Bologna in data 21.7.05, dichiara l'appellante XXXXX responsabile del reato di cui all'art. 615 quinquies c.p. e con le già concesse attenuanti generiche determina la pena in mesi due di reclusione ed euro 2.000 di multa, sostituendo la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria di euro 2.280 di multa, e così complessivamente euro 4.280 di multa, che dichiara interamente condonata ex L. 241\06.

Dichiara non doversi procedere nei confronti dell' appellante XXXXX in ordine al reato di cui all' art. 615 ter c.p., perché, esclusa l'aggravante, lo stesso è improcedibile per difetto di querela.

Conferma nel resto.

Indica in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.

INTERNATIONAL TRADERS
www.intertraders.eu

Bologna, 30.01.08

Il Consigliere est.
Dott. Domenico Pasquariello

Il Presidente
Dott. Salvatore Guarino

Depositata in cancelleria il **27.03.2008**

INTERNATIONAL TRADERS
www.intertraders.eu